



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 18

**Abgrenzung des Gewerbebetriebs von
der Vermögensverwaltung**

73

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ABGRENZUNG DES GEWERBEBETRIEBS VON DER VERMÖGENSVERWALTUNG	1
1.	Allgemeines	1
1.1	Vermögensverwaltung	1
1.2	Gewerbebetrieb	2
2.	Die Fruchtziehung aus dem Vermögen	3
2.1	Zuordnungsentscheidung des Steuerpflichtigen	3
2.2	Vermietung von Ferienwohnungen	3
2.3	Betriebsaufspaltung	3
2.4	Betriebsverpachtung/Ruhender Gewerbebetrieb	3
3.	Anschaffung und Veräußerung von Vermögen	4
3.1	Wertpapiergeschäfte	4
3.2	Grundstücksgeschäfte	5
3.2.1	Folgen der Abgrenzung des Gewerbebetriebs von der Vermögensverwaltung bzw. land- u. forstwirtschaftlichen Hilfsgeschäften	5
3.2.2	Der gewerbliche Grundstückshandel	5
3.2.3	Der doppelte Fünfjahreszeitraum	6
3.2.4	Die maßgeblichen Objekte i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels	7
3.2.5	Die „Zählobjekte“	11
3.2.6	Die Drei-Objekt-Grenze	11
3.2.7	Beginn, Umfang und Beendigung des gewerblichen Grundstückshandels, Gewinnermittlung	17
II.	LIEBHABEREI IM EINKOMMENSTEUERRECHT	20
1.	Begriff	20
2.	Einkünfteerzielungsabsicht	20
3.	Persönlicher Geltungsbereich	20
III.	ÜBUNGSFÄLLE	22
1.	Übungsfall 1	22
2.	Übungsfall 2	22
3.	Übungsfall 3	22



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 18 – Überblick – v13913



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Grundlagen zur Abgrenzung des Gewerbebetriebs zur Vermögensverwaltung und die Liebhaberei erläutert.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes

- können Sie erkennen, ob ein Gewerbebetrieb oder eine Vermögensverwaltung gegeben ist,
- können Sie die steuerlichen Folgen des gewerblichen Grundstückshandels beurteilen,
- können Sie Sachverhalte unter den Begriff „Liebhaberei“ subsumieren.



PRÜFUNGSTIPP

Die Abgrenzung zur Vermögensverwaltung ist gelegentlich Gegenstand der Prüfungsklausuren, z. B.: Immobilienveräußerung durch PersG (2021), Vermietung eines Ferienhauses (2024).

I. ABGRENZUNG DES GEWERBEBETRIEBS VON DER VERMÖGENSVERWALTUNG

1. Allgemeines

1.1 Vermögensverwaltung

Erträge in Zusammenhang mit Vermögenswerten können einerseits durch Fruchtziehung aus dem Vermögen (z. B. Mietzinsen, Dividenden usw.) und andererseits durch Verwertung des Vermögens (z. B. Veräußerung) erzielt werden.



HINWEIS

Eine Vermögensverwaltung liegt nur dann vor, wenn sich die Betätigung als Nutzung von Vermögen i. S. einer Fruchtziehung aus den zu erhaltenden Substanzwerten darstellt und die Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch Umschichtung des Vermögens nicht entscheidend in den Vordergrund tritt (R 15.7 Abs. 1 Satz 2 EStR).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeine Abgrenzung – v10611



1.2 Gewerbebetrieb

Ein Gewerbebetrieb liegt vor, wenn eine selbständige nachhaltige Betätigung mit Gewinnabsicht unternommen wird, die sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht und weder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft noch Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit darstellt (§ 15 Abs. 2 Satz 1 EStG, R 15.7 Abs. 1 Satz 3 EStR).

Selbständigkeit: Selbständigkeit setzt voraus, dass eine natürliche Person auf eigene Rechnung und Gefahr tätig ist, also das Erfolgsrisiko der eigenen Betätigung trägt (Unternehmerrisiko) und Unternehmerinitiative entfalten kann. Vgl. H 15.1 EStH „Allgemeines“.

Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit setzt voraus, dass die Betätigung auf Wiederholung angelegt sein muss. Entscheidend ist die Wiederholungsabsicht des Stpfl., die sich nur aus äußeren Umständen bestimmen lässt. Nachhaltigkeit ist daher bei einer Mehrzahl von gleichartigen Handlungen in der Regel zu bejahen.

► **Beispiel:**

Ein Briefmarkensammler verkauft Briefmarken bei jeder günstigen Gelegenheit.

► **Lösung:**

Der Briefmarkensammler ist nachhaltig tätig, da seine Betätigung auf Wiederholung angelegt ist.

► **Beispiel:**

Ein Briefmarkensammler verkauft grundsätzlich keine Briefmarken. Allerdings hat er eine Ausnahme gemacht, als er im Gegenzug eine sehr seltene Briefmarke für den Verkauf von zwei bisher ihm gehörenden Briefmarken bekommen hat.

► **Lösung:**

Der Briefmarkensammler ist nicht nachhaltig tätig, da seine Betätigung nicht auf Wiederholung angelegt ist.

Bei erkennbarer Wiederholungsabsicht kann bereits eine einmalige Handlung den Beginn einer fortgesetzten Tätigkeit begründen; dies gilt selbst dann, wenn zwar der Wiederholungsentschluss gefasst ist, eine tatsächliche Wiederholung aber z. B. mangels Gelegenheit unterbleibt (H 15.2 EStH „Wiederholungsabsicht“).

Gewinnerzielungsabsicht: Die Gewinnerzielungsabsicht ist ein subjektives Tatbestandsmerkmal, auf dessen Vorliegen oder Fehlen aber nicht aus Erklärungen des Stpfl., sondern nur aus äußerlich erkennbaren, objektiv tatsächlichen Merkmalen („Indizien“) geschlossen werden kann.

Erforderlich ist das Streben nach einer Betriebsvermögensmehrung in Form eines Totalgewinns in der Totalperiode. Bei einem neu eröffneten Betrieb muss eine Prognose zu einem positiven Gesamtergebnis in der Zeit von der Gründung bis zur Veräußerung oder Aufgabe führen.

Bei bestehenden Betrieben sind im Rahmen der Prognose die in der Vergangenheit erzielten Gewinne unbeachtlich (H 15.3 EStH „Totalgewinn“). Veräußerungs- und Aufgabegewinne sind einzubeziehen, auch soweit dieser Gewinn z. B. nach § 16 Abs. 4 EStG steuerfrei ist. Eine durch die Betätigung verursachte Minderung der Steuern vom Einkommen ist dabei kein Gewinn (§ 15 Abs. 2 Satz 2 EStG; z. B. bei Beteiligung an Verlustzuweisungsgesellschaften oder bei Beschäftigung von Angehörigen).

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr: Erforderlich ist, dass der Stpfl. als Anbieter von Gütern oder Leistungen, auch immaterieller Art, am Markt gegen Entgelt und für Dritte äußerlich erkennbar auftritt (H 15.4 EStH „Allgemeines“).

Erkennbar angeboten wird die Tätigkeit auch dann, wenn sie nur einem kleinen Kreis oder gar einem einzigen Marktteilnehmer angeboten wird. Maßgeblich ist dabei allein die Erkennbarkeit für einen oder mehrere Auftraggeber. Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr kann auch dann vorliegen, wenn Leistungen entgeltlich nur Angehörigen gegenüber erbracht werden (H 15.4 EStH „Kundenkreis“).

2. Die Fruchtziehung aus dem Vermögen

Selbst bei einer Betätigung, die nach außen ausschließlich auf die Erzielung einer laufenden Rendite aus vorhandenen Vermögenswerten gerichtet ist, muss eine klare Abgrenzung gegenüber Einkünften aus Gewerbebetrieb vorgenommen werden. Die nachfolgenden Sachverhalte sollen diese Problematik verdeutlichen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gewerbliche Vermietung – v10612

2.1 Zuordnungsentscheidung des Steuerpflichtigen

Werden WG, z. B. vermietete Grundstücke, durch den Stpfl. zulässigerweise als gewillkürtes BV behandelt, stellen die Mietzinsen Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar (Subsidiaritätsklauseln; z. B. § 21 Abs. 3 EStG, § 20 Abs. 8 EStG i. V. m. § 15 EStG).

2.2 Vermietung von Ferienwohnungen

Die Vermietung (einer oder) mehrerer Ferienwohnungen in Gewinnabsicht ist ein Gewerbebetrieb, wenn sich die Vermietung anhand der Umstände des Einzelfalls als „hotelmäßige“ Vermietung darstellt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn

- die Wohnung zur Führung eines Haushalts voll eingerichtet ist, zu einer einheitlichen Wohnanlage gehört, jederzeit zur Vermietung bereitgehalten wird, die Werbung und Verwaltung einer Feriendienstorganisation übertragen ist und nach Art der Rezeption eines Hotels laufend Personal anwesend ist, das mit den Feriengästen Mietverträge abschließt und abwickelt und die Wohnung erhält und reinigt oder
- wegen der Häufigkeit des Gästewechsels bzw. im Hinblick auf zusätzlich erbrachte Leistungen (z. B. Bereitstellung von Wäsche und Mobiliar, Übernahme sozialer Betreuung, Reinigung der Räume) eine fremdenpensionsartige Organisation erforderlich ist.

Vgl. dazu H 15.7 Abs. 2 EStH „Ferienwohnung“, H 4.2 Abs. 7 EStH „Ferienwohnung“.

Wegen Besonderheiten bei der Prüfung der Einkunftserzielungsabsicht (z. B. bei teilweiser Selbstnutzung, Behandlung von Leerstandszeiten usw.) vgl. BMF v. 8.10.2004, BStBl 2004 I S. 933, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/5.

2.3 Betriebsaufspaltung

Die Nutzungsüberlassung eines WG im Rahmen einer Betriebsaufspaltung führt ebenfalls zu Einkünften aus Gewerbebetrieb („Besitzunternehmen“). Entscheidend für diese Beurteilung ist, dass die hinter dem Besitz- und Betriebsunternehmen stehenden Personen (Person) einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben, der (über das Betriebsunternehmen – **Durchgriff**) auf die Ausübung einer gewerblichen Betätigung gerichtet ist.

2.4 Betriebsverpachtung/Ruhender Gewerbebetrieb

Die Vermietung/Verpachtung außerhalb einer aktiven gewerblichen Betätigung kann zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führen, wenn die Voraussetzungen der Betriebsverpachtung oder eines ruhenden Gewerbebetriebs („Betriebsunterbrechung“) vorliegen. Maßgebend ist hierbei, dass im Vorfeld ein werbender Gewerbebetrieb bestanden hat und bisher keine ausdrückliche Aufgabe der gewerblichen Tätigkeit erklärt wurde (§ 16 Abs. 3b Satz 1 Nr. 1 EStG).



3. Anschaffung und Veräußerung von Vermögen

3.1 Wertpapiergeschäfte

Der Vermögensanlage in Wertpapieren ist eigen, dass die Fruchtziehung nicht notwendigerweise im Zufluss von Zinsen und Dividenden besteht, sondern sich die Ertragserwartung des Anlegers wirtschaftlich auch aus der Kursentwicklung ergeben kann. Dementsprechend hatte schon der Reichsfinanzhof (RFH) entschieden, dass die Berücksichtigung der späteren Möglichkeit günstiger Weiterveräußerung – selbst bei Gegenständen, die gar keinen laufenden Ertrag gewähren können – dem Begriff der privaten Vermögensverwaltung nicht widerspricht. Bei Wertpapieren liegt es in der Natur der Sache, den Bestand zu verändern, schlechte Papiere abzustoßen, gute zu erwerben und Kursgewinne zu realisieren. Die Verkehrsauffassung sieht die Umschichtung von Wertpapieren – selbst in erheblichem Umfang – regelmäßig als noch zur privaten Vermögensverwaltung gehörig an; Gewerblichkeit kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (H 15.7 Abs. 9 EStH „An- und Verkauf von Wertpapieren“).

Mit BFH, Urteil v. 30.7.2003 – X R 7/99, BStBl 2004 II, S. 408 hat der BFH die Annahme eines Gewerbebetriebs bei Wertpapiergeschäften präzisiert. Nach dieser Entscheidung „überschreitet der An- und Verkauf von Wertpapieren grundsätzlich noch nicht den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung, sofern die entfaltete Tätigkeit dem Bild eines „Wertpapierhandelsunternehmens“ i. S. d. § 1 Abs. 3d Satz 4 KWG a. F. bzw. eines „Finanzunternehmens“ i. S. d. § 1 Abs. 3 KWG nicht vergleichbar ist“.

Aus den Entscheidungsgründen des BFH ergeben sich folgende Tatbestandsvoraussetzungen für die Annahme eines gewerblichen Wertpapierhandels:

- Der Stpfl. muss „für andere“ bzw. für fremde Rechnung tätig werden („Wertpapierhandelsunternehmen“) oder unmittelbar mit anderen Marktteilnehmern Handel treiben („Finanzunternehmen“). Die bloße Erteilung eigener Kauf- und Verkaufsaufträge an die depotführende Bank bzw. verschiedene Depotbanken ist ohne Bedeutung. Durch ein solches Verhalten wird der Stpfl. noch nicht zum unmittelbaren Marktteilnehmer. Die Bank wird von der Verkehrsanschauung ebenso wenig als Kunde des Anlegers angesehen wie die anonym bleibenden Kontrahenten.
- Ein gewerblicher Wertpapierhandel erfordert auch ein Mindestmaß an kaufmännischer Organisation. Für Wertpapierhandelsunternehmen folgt dies schon aus dem Erfordernis eines in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetriebs (§ 1 Abs. 1 Satz 1 KWG bzw. § 1 Abs. 1a Satz 1 KWG), für Finanzunternehmen aus dem Begriffsbestandteil „Unternehmen“. Die büromäßige Einrichtung einer „Privatperson“ hat angesichts des Wandels, den die private Anlagetätigkeit genommen hat, nur noch geringe Bedeutung. Denn auch dem privaten Anleger steht mittlerweile die Möglichkeit offen, beim An- und Verkauf von Wertpapieren handelsübliche PC und einschlägige Standard-Software einzusetzen. Entscheidend ist hierbei vielmehr, ob der Stpfl. an professionelle Handelssysteme angeschlossen ist oder nicht.
- Die Fremdfinanzierung von Wertpapiergeschäften ist aus heutiger Sicht, in Anbetracht der veränderten Gewohnheiten von Privatanlegern, kein Kriterium für die Annahme der Gewerblichkeit.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wertpapierhandel – v10613

3.2 Grundstücksgeschäfte

3.2.1 Folgen der Abgrenzung des Gewerbebetriebs von der Vermögensverwaltung bzw. land- u. forstwirtschaftlichen Hilfsgeschäften

Erfolgt eine Grundstücksveräußerung im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung, können Einkünfte nur dann vorliegen, sofern die Veräußerung innerhalb der Haltefrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erfolgt; ansonsten ist die Veräußerung nicht steuerbar. Veräußerungsgewinne sind in diesen Fällen nur bei Überschreiten der Freigrenze (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG) steuerpflichtig; Verluste sind nur einkunftsbezogen ausgleichsfähig (§ 23 Abs. 3 Satz 7, 8 EStG).

Erfolgt die Veräußerung jedoch im Rahmen eines Gewerbebetriebs, liegen Einkünfte gem. § 15 EStG vor; Verluste sind ausgleichs- und abzugsfähig (§ 2 Abs. 3 EStG, § 10d EStG). Die steuerlichen Nachteile ergeben sich einerseits daraus, dass die Gewinne nach § 2 GewStG gewerbesteuerpflichtig sind (allerdings Anrechnung der GewSt im Rahmen des § 35 EStG), andererseits aus der Qualifizierung der gehandelten Objekte als Umlaufvermögen (BMF v. 26.3.2004, BStBl 2004 I, S. 434, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 15/1 (kurz: BMF 1 § 15/1), Rz. 33). Letzteres schließt die Geltendmachung einer AfA für Gebäude und einer Rücklage nach § 6b EStG aus. Ferner ist zu berücksichtigen, dass ein steuerbegünstigter Betriebsveräußerungs- bzw. Aufgabegewinn (§ 16 EStG) hinsichtlich der Grundstücke im Betriebsvermögen ausgeschlossen ist und dass Kürzungen nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht in Betracht kommen.

Die Parzellierung und Veräußerung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke, unabhängig von der Fläche, der Anzahl der Parzellen und der Höhe des Gewinns, stellen grundsätzlich Hilfsgeschäfte des L+F-Betriebs dar (H 15.5 EStH „Grundstücksverkäufe“). Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt nur dann vor, falls die Aktivitäten über eine Parzellierung und Veräußerung hinausgehen und darauf gerichtet sind, Objekte anderer (höherer) Marktgängigkeit zu schaffen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundstückshandel – v10614

3.2.2 Der gewerbliche Grundstückshandel

Das zentrale Problem der Abgrenzung des Gewerbebetriebs von der privaten Vermögensverwaltung liegt in der Frage der „**Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr**“.

Die BFH-Rechtsprechung orientiert sich hierbei typisierend am klassischen Grundstückshändler, Bauträger bzw. Baulanderschließungsunternehmen.

Wesentliches Abgrenzungsmerkmal ist der sog. gewerbliche Betätigungswille, durch den der Steuerpflichtige zum Ausdruck bringt, dass er Grundstücke erwirbt, Gebäude errichtet bzw. grundlegend modernisiert, um sie später mit Gewinn weiterveräußern zu können, d. h. um Wertsteigerungen eines Grundstücks realisieren zu können. Da es sich hierbei jedoch um ein subjektives Tatbestandsmerkmal handelt, bestehen große Schwierigkeiten, diesen Betätigungswillen nachzuweisen. Daher wurden in Rechtsprechung und Literatur objektive Kriterien entwickelt, die den Schluss auf einen gewerblichen Betätigungswillen erleichtern und die Gleichheit der Rechtsanwendung auf alle Steuerpflichtigen gewährleisten sollen – diese äußeren Merkmale („Indizien“) werden in der Regel aus dem zeitlichen Zusammenhang zwischen der Anschaffung, Herstellung oder grundlegenden Modernisierung und der Veräußerung sowie der Zahl der veräußerten Objekte ersichtlich.

Nach der Lebenserfahrung kann eine **bedingte Veräußerungsabsicht** („In-Erwägung-Ziehen“) aus einem engen zeitlichen Zusammenhang (Fünfjahreszeitraum) zwischen dem Erwerb, der Errichtung oder der grundlegenden Modernisierung und der Veräußerung gezogen werden. Veräußerungen wegen Finanzierungsschwierigkeiten, zur Vermeidung einer Zwangsversteigerung, einer zu hohen finanziellen Belastung oder die Belastung durch Scheidungsfolgen entkräften die



bedingte Veräußerungsabsicht grds. nicht. Nur wenn von Anfang an eindeutige Anhaltspunkte (vom Steuerpflichtigen darlegungs- und beweispflichtig) dafür vorliegen, dass eine Veräußerung objektiv nicht in Betracht gezogen wurde, hat der enge zeitliche Zusammenhang für sich genommen keine Bedeutung, BMF 1 § 15/1, Rz. 21.

Des Weiteren ist die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr durch den Kontakt zu einer Mehrzahl von Verkäufern oder Käufern gekennzeichnet; sie kann aber z. B. auch vorliegen

- bei einer Tätigkeit für nur einen Vertragspartner oder bei Einschaltung eines Maklers oder
- bei einer Verkaufsabsicht an einen nur kleinen Personenkreis – unter Umständen einer einzigen Person –, falls der Verkäufer damit rechnet, dass sich die Verkaufsabsicht herumsprechen wird. Entscheidend ist, dass der Verkäufer an jeden, der die Kaufbedingungen erfüllt, verkaufen will. Das ist bereits dann der Fall, wenn er bereit ist, das fragliche Objekt an einen anderen Erwerber zu veräußern, falls sich der Verkauf an den ursprünglich vorgesehenen Käufer zerschlägt.

Vgl. hierzu BMF 1 § 15/1 Rz. 4.

3.2.3 Der doppelte Fünfjahreszeitraum

Die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist durch einen doppelten Fünfjahreszeitraum geprägt:

1. Zum einen muss zwischen dem Erwerb, der Herstellung oder der grundlegenden Modernisierung eines Objektes und dessen Veräußerung ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen; nach der Rechtsprechung ist dies grundsätzlich ein Fünfjahreszeitraum (sog. **Haltezeitraum**). Er wird als Anscheinsbeweis für die erforderliche (zumindest bedingte) Veräußerungsabsicht gewertet (BMF 1 § 15/1, Rz. 19–24).

Unter besonderen Voraussetzungen (z. B. Branchenkunde des Steuerpflichtigen) kann dieser Haltezeitraum länger zu fassen sein, längstens jedoch für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren (starre Obergrenze!, Begründung siehe BMF 1 § 15/1, Rz. 2 Satz 1). Als „branchenkundig“ sind z. B. Architekten, Bauingenieure, Bauunternehmer, Baubetreuer und Grundstücksmakler sowie deren Angehörige anzusehen.

Der Haltezeitraum beginnt im Falle der Anschaffung mit dem Abschluss des obligatorischen Rechtsgeschäftes, bei der Errichtung im Zeitpunkt der Fertigstellung des Objekts (BMF 1 § 15/1, Rz. 20) und bei einer grundlegenden Modernisierung mit Abschluss der Sanierungsarbeiten (BMF 1 § 15/1, Rz. 24). Bei der Errichtung oder Modernisierung ist der Zeitpunkt der Anschaffung unbeachtlich.

Werden erworbene Grundstücke parzelliert oder ein erworbenes Mietwohngrundstück in Eigentumswohnungen aufgeteilt und anschließend veräußert, so bemisst sich der Haltezeitraum unverändert von der Anschaffung bis zur Veräußerung. Nur wenn der Stpfl. die Eigentumswohnungen grundlegend modernisiert, beginnt die Haltefrist neu zu laufen. Vergleichbares gilt, wenn der Stpfl. beginnt, sich nach der Parzellierung an der Erschließung des Grundstücks aktiv zu beteiligen – „Baulandreifmachung“ (BMF 1 § 15/1, Rz. 2 vorletzter Satz, Rz. 3, 19, 23, 26).

2. Zum anderen werden nur Veräußerungen betrachtet, die innerhalb eines Fünfjahreszeitraums erfolgen (sog. **Veräußerungszeitraum**). Er dient dazu, einen gewissen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang sicherzustellen, damit von einem einheitlichen Betätigungswillen gesprochen werden kann. Dieser Fünfjahreszeitraum ist allerdings nicht starr zu sehen: Nach der Rechtsprechung des BFH ist z. B. auch eine höhere Zahl von Veräußerungen zu berücksichtigen, die kurze Zeit nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums erfolgen.

Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BMF 1 § 15/1, Rz. 5, 6, 20).

Die Fünfjahreszeiträume sind nicht kalenderjahrbezogen zu ermitteln. Maßgebend ist der tatsächliche zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Veräußerungstatbeständen bzw. für den einzelnen Veräußerungstatbestand der tatsächliche Zeitraum zwischen Anschaffung, Errichtung oder grundlegender Modernisierung des Objekts und dessen Veräußerung.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Doppelter Fünfjahreszeitraum – v10615

3.2.4 Die maßgeblichen Objekte i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zählobjekte – v10616

3.2.4.1 Allgemeines

Objekt i. S. eines gewerblichen Grundstückshandels ist grds. jedes selbständig veräußerbare und nutzbare Immobilienobjekt (Grundstück, grundstücksgleiches Recht oder Recht nach dem WEG). Darunter fallen unbebaute und bebaute Grundstücke jeglicher Art – neben Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen auch Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten (Hotel-, Büro-, Fabrik- und Lagergrundstücke). Auf die Größe, den Wert oder die Nutzungsart des einzelnen Objekts kommt es nicht an. Die selbständige Veräußerbarkeit folgt der sachenrechtlichen Qualifizierung, wird jedoch durch wirtschaftliche Gesichtspunkte unter Beachtung der Verkehrsanschauung geprägt.

Allerdings bleiben Grundstücke grundsätzlich außer Ansatz, die bis zur Veräußerung während eines langen Zeitraums (mindestens 10 Jahre) vermietet wurden (BMF 1 § 15/1, Rz. 2 Satz 1).

Für die Bestimmung des Grundstücks ist eine Einteilung in Flurstücke i. S. d. Vermessungs- bzw. Katasterwesens unbeachtlich; entscheidend ist die Einordnung i. S. d. BGB und der Grundbuchordnung (GBO).

Ein ungeteiltes Mehrfamilienhaus zählt nur als ein Objekt. Erst die Teilung in Eigentumswohnungen nach dem WEG schafft die zivilrechtlichen Voraussetzungen für die Entstehung selbständiger Objekte. Jedes aus der Teilung entstandene Wohnungseigentum ist dann ein Objekt. Demgegenüber stellt jedoch ein Garagenabstellplatz kein eigenständiges Objekt dar, wenn er als Zubehörraum zusammen mit einer Eigentumswohnung veräußert wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Garagenabstellplatz im Zusammenhang mit der Veräußerung der Eigentumswohnung an andere Erwerber als die Käufer der Eigentumswohnung veräußert wird.

Auch Erbbaurechte kommen als Objekte in Betracht. Hierbei ist zu beachten, dass die (bloße) Bestellung von Erbbaurechten nicht genügt. Objekte sind erst bei der entgeltlichen Veräußerung von Erbbaurechten – aufgrund der Eigenschaft als grundstücksgleiches Recht – gegeben (BMF 1 § 15/1, Rz. 8, 26.)

► **Beispiel:**

C erwarb in 04 und 06 jeweils eine Eigentumswohnung samt Garagenstellplatz. In 10 veräußert C die bis zu diesem Zeitpunkt vermieteten Eigentumswohnungen. Da keiner der Käufer Interesse an dem jeweiligen Garagenstellplatz zeigte, wurden diese an andere Interessenten in der jeweiligen Wohnanlage verkauft.



► **Lösung:**

Ein Garagenabstellplatz stellt kein eigenständiges Objekt i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels dar, wenn er als Zubehörraum zusammen mit einer Eigentumswohnung veräußert wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Garagenabstellplatz im Zusammenhang mit der Veräußerung der Eigentumswohnung an andere Erwerber als die Käufer der Eigentumswohnung veräußert wird (BMF 1 § 15/1, Rz. 8).

C erzielt daher sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), da zwischen der Anschaffung (04 bzw. 06) und der Veräußerung (10) nicht mehr als 10 Jahre liegen.

3.2.4.2 Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

Bebaute Grundstücke, die bislang zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden, sind i. d. R. für die Beurteilung eines gewerblichen Grundstückshandels unbeachtlich und stellen damit keine maßgebenden Objekte dar. Sie gehören regelmäßig – von besonders gelagerten, namentlich bei einer nur kurzfristigen, vorübergehenden Eigennutzung in Betracht kommenden Ausnahmefällen abgesehen – zum notwendigen Privatvermögen. Der BFH hat ebenso die Zuordnung von selbst nur vorübergehend, über einen Zeitraum von weniger als fünf Jahren eigengenutzten Wohnobjekten – anders als bei vermieteten Objekten – zum Umlaufvermögen eines gewerblichen Grundstückshandels verneint, wenn der Steuerpflichtige den Verkauf mit „offensichtlichen Sachzwängen“ (z. B. beruflich bedingte örtliche Veränderungen, Umzug in eine näher am Arbeitsplatz gelegene Wohnung, größerer Platzbedarf durch Familienzuwachs, Trennung der Eheleute) zu rechtfertigen vermag (BMF 1 § 15/1, Rz. 10).

► **Beispiel:**

B veräußerte in 10 seine bisher eigengenutzte Eigentumswohnung in Nürnberg (Anschaffung in 06), da er in München zusammen mit seiner neuen Lebensgefährtin C eine Wohnung bezog. Nach dem Umzug nach München nahm B auch eine neue Tätigkeit in München auf.

► **Lösung:**

Bebaute Grundstücke, die bislang zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden, sind i. d. R. für die Beurteilung eines gewerblichen Grundstückshandels unbeachtlich und stellen damit keine maßgebenden Objekte (Zählobjekte) dar. Sie gehören regelmäßig zum notwendigen Privatvermögen.

3.2.4.3 Grundstücke, die ohne Gewinnerzielungsabsicht veräußert werden

Grundstücke, die entgegen der ursprünglichen Absicht des Stpfl. mit Verlust veräußert wurden, stellen ein „Objekt“ dar. Grundstücke, mit deren Weitergabe kein Gewinn erzielt werden soll (teilentgeltliche Veräußerung, bei der die Selbstkosten nicht überschritten werden oder Schenkung an Angehörige), bleiben als „Objekte“ grds. außer Betracht.

Eine Ausnahme ergibt sich nur dann, wenn der Stpfl. vor unentgeltlicher oder teilentgeltlicher Übertragung eine bedingte Veräußerungsabsicht hatte (BMF 1 § 15/1, Rz. 11).

3.2.4.4 Unentgeltlicher Erwerb im Rahmen der Einzelrechtsnachfolge

In die Prüfung des gewerblichen Grundstückshandels und damit der „Objekte“ sind Grundstücke, die unentgeltlich im Wege der vorweggenommenen Erbfolge oder durch Schenkung erworben wurden, grundsätzlich nicht mit einzubeziehen. Ein unentgeltlicher Erwerb stellt keine Anschaffung dar.

Die fehlende Anschaffung ist jedoch unbeachtlich, falls über die Veräußerung der unentgeltlich erworbenen Objekte hinaus erhebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verwertungsmöglichkeiten unternommen wurden (umfangreiche Modernisierung, Erschließung, Baureifmachung). Der maßgebende Haltezeitraum beginnt in diesen Fällen nicht mit dem Erwerb, sondern mit dem Abschluss der wertsteigernden Maßnahmen (BFH, Urteil v. 20.4.2006, BStBl 2007 II, S. 375).

Nach BMF 1 § 15/1, Rz. 9 sind unentgeltlich im Rahmen der Einzelrechtsnachfolge übertragene Grundstücke als Objekte zu berücksichtigen, falls diese vom Rechtsnachfolger im zeitlichen Zusammenhang veräußert werden. Die Berechnung des Haltezeitraums erfolgt hier nicht allein anhand der Besitzdauer des Rechtsnachfolgers, vielmehr wird ihm auch die Besitzdauer des Rechtvorgängers zugerechnet (BMF 1 § 15/1, Rz. 9, 2 Satz 3).

3.2.4.5 Unentgeltlicher Erwerb im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge

Nicht einzubeziehen sind Grundstücke, die durch Erbfolge übergegangen sind, und zwar auch dann nicht, wenn der ererbte Grundbesitz sehr umfangreich ist. Denn der Erwerb kraft Gesamtrechtsnachfolge ist keine Anschaffung eines Objekts i. S. d. Rechtsprechung zum gewerblichen Grundstückshandel und es ist außerdem in der Regel keine bedingte Veräußerungsabsicht in der Person des Erben gegeben. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn

- bereits der Erblasser in seiner Person einen gewerblichen Grundstückshandel begründet hat und der Erbe einen unternehmerischen Gesamtplan fortführt oder
- der Erbe bei unbebauten Grundstücken hierauf ein Gebäude errichtet bzw. bei bebauten Grundstücken das aufstehende Gebäude vor Veräußerung grundlegend modernisiert – denn in diesen Fällen setzt der Erbe selbst eine Ursache, die bei zeitnaher Veräußerung des Objekts auf eine bedingte Veräußerungsabsicht schließen lässt (BMF 1 § 15/1, Rz. 9).

3.2.4.6 Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften/-gemeinschaften



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beteiligungen an PersG – v10617

3.2.4.6.1 Ebene der Personengesellschaften bzw. -gemeinschaften (z. B. GbR oder Erbengemeinschaft)

„Objekte“ auf der Ebene der Personengesellschaft sind nur **deren** erworbene bzw. bebaute und veräußerte, nicht hingegen die Objekte der Gesellschafter, die diese selbst und/oder über weitere Personengesellschaften an- und verkaufen. Die Beurteilung auf der Ebene der Gesellschaft ist vorrangig und wird nicht durch die Veräußerungen der Gesellschafter „infiziert“ (BMF 1 § 15/1, Rz. 14).

Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für Bruchteilsgemeinschaften i. S. v. § 741 BGB, § 1008 BGB (BMF 1 § 15/1, Rz. 18).

Wird eine Personengesellschaft oder Bruchteilsgemeinschaft **real geteilt**, wobei jeder Gesellschafter bzw. Miteigentümer Objekte zu Alleineigentum erhält, liegen insoweit keine „Objekte“ der Personengesellschaft/-gemeinschaft vor. Dies gilt selbst dann, wenn im Rahmen der Realteilung Schulden der Gesellschaft oder Gemeinschaft übernommen werden und diese die Beteiligungsquote übersteigen. Auch spätere Veräußerungen der Realteiler auf eigene Rechnung bleiben bei der Beurteilung der Personengesellschaft bzw. Bruchteilsgemeinschaft als solcher außer Betracht (BMF 1 § 15/1, Rz. 13, 7).

3.2.4.6.2 Ebene der Gesellschafter

a) Objektveräußerungen

Ist ein Stpfl. an einer oder mehreren Personengesellschaften (z. B. auch Erbengemeinschaft oder Bruchteilsgemeinschaft) beteiligt, sind neben seinen eigenen Grundstücksaktivitäten (Erwerb, Bebauung und Veräußerung) die Grundstücksgeschäfte der Personengesellschaft wie eigene Aktivitäten (= „Objekte“) des Stpfl. zu berücksichtigen; die Personengesellschaft/-gemeinschaft entfaltet keine Abschirmwirkung; die Frage, ob die Gesellschaft für sich einen Gewerbebetrieb unterhält oder nur vermögensverwaltend tätig ist, ist hierbei unbeachtlich.



Voraussetzung für diesen Durchgriff ist jedoch, dass

- der Gesellschafter an der jeweiligen Gesellschaft zu mindestens 10 % beteiligt ist oder dass der Verkehrswert des Gesellschaftsanteils oder des Anteils an dem veräußerten Grundstück mehr als 250.000 € beträgt (BMF 1 § 15/1, Rz. 14, 17) **und**
- zwischen den Aktivitäten der Personengesellschaft und des Gesellschafters ein Sachzusammenhang besteht. Ein derartiger Sachzusammenhang fehlt bei einer gewerblich tätigen Personengesellschaft, deren Zweck nicht auf Grundstücksaktivitäten, sondern z. B. auf den Betrieb einer Maschinenfabrik gerichtet ist – in diesem Fall stellen Grundstücksverkäufe der Gesellschaft keine „Objekte“ für den Gesellschafter dar.

b) Anteilsveräußerungen

Den Grundstücksveräußerungen sind Veräußerungen der Anteile an gewerblichen oder nur vermögensverwaltenden Gesellschaften grds. gleichgestellt (Folge aus § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO). Der Verkauf des Gesellschaftsanteils führt auf der Ebene des Gesellschafters zu so vielen Objekten, wie sich im Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft befinden (BMF 1 § 15/1, Rz. 18). Entsprechendes gilt auch, wenn nur ein Teil eines Gesellschaftsanteils veräußert wird.

Voraussetzung für die Annahme eines „Objekts“ (Durchgriff) ist auch hier, dass

- der Gesellschafter an der jeweiligen Gesellschaft zu mindestens 10 % beteiligt ist oder dass eine Beteiligung einen Verkehrswert von mehr als 250.000 € hat (BMF 1 § 15/1, Rz. 18) und
- zwischen den Aktivitäten der Personengesellschaft und des Gesellschafters ein Sachzusammenhang besteht.

c) Fehlende Veräußerung eigener Objekte

Ein Stpfl. kann einen gewerblichen Grundstückshandel auch dann betreiben, wenn er in eigener Person kein einziges Objekt veräußert, aber durch die Zurechnung der Grundstücksverkäufe von Personengesellschaften oder Gemeinschaften die Voraussetzungen eines gewerblichen Grundstückshandels erfüllt sind (BFH, Urteil v. 22.4.2015 – X R 25/13, BStBl. II 2015, S. 897).

3.2.4.7 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

Nicht erwähnt wird in dem BMF 1 § 15/1 wie sich eine Beteiligung an einer grundstücksbesitzenden Kapitalgesellschaft auf die „Objekte“ des Anteilseigners auswirken kann. Damit stellt sich die Frage, ob wie bei Personengesellschaften für die Bestimmung der Objekte durch eine Kapitalgesellschaft „durchgegriffen“ werden kann.

Einen unmittelbaren Durchgriff durch die Kapitalgesellschaft lehnt der BFH grundsätzlich ab. Die Kapitalgesellschaft ist nicht nur zivil-, sondern auch steuerrechtlich ein selbständiges Steuersubjekt.

Die Abschirmwirkung einer Kapitalgesellschaft wird nach Auffassung des BFH nur dann durchbrochen, wenn im konkreten Einzelfall Bedingungen vereinbart sind, die den Schluss zulassen, dass ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i. S. von § 42 Abs. 1 AO vorliegt. Für einen Gestaltungsmissbrauch kann insbesondere sprechen, dass die Mittel für den an den Anteilseigner zu entrichtenden Kaufpreis zu einem wesentlichen Teil aus den Erlösen für den Weiterverkauf aufzubringen sind. Die Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH ist nach BFH, Urteil v. 17.3.2010, BStBl 2010 II, S. 622 nicht rechtsmissbräuchlich.

3.2.4.8 Übertragung eines Grundstücks auf eine Personen- oder Kapitalgesellschaft

BMF 1 § 15/1, Rz. 7.

3.2.4.8.1 Übertragung auf eine Personengesellschaft

Die Übertragung eines Grundstücks aus dem Privatvermögen in das betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten ist als Veräußerung und damit als Objekt anzusehen (BMF v. 29.3.2000, BStBl 2000 I, S. 462, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/13 Tz. II. 1a). Gleiches gilt auch bei einer Übertragung aus dem Betriebsvermögen in das betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, unabhängig davon, dass in diesen Fällen die Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG gegeben ist (BMF v. 8.12.2011, BStBl 2011 I, S. 1279, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/15, Rz. 8).

Ein Objekt liegt auch bei der Übertragung eines Grundstücks gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auf eine vermögensverwaltende Personengesellschaft vor (anteilige Veräußerung; BMF v. 5.10.2000, BStBl 2000 I, S. 1383, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 23/1, Rz. 8).

Unentgeltliche Übertragungen in das Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft, gleichgültig ob aus Betriebs- oder Privatvermögen, stellen mangels Veräußerungen keine Objekte dar.

3.2.4.8.2 Übertragung auf eine Kapitalgesellschaft

Die Einbringung eines Grundstücks in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten stellt eine Veräußerung und damit ein Objekt dar. Dies gilt auch in Mischfällen, in denen die dem Gesellschafter gewährte angemessene Gegenleistung teilweise in der Gewährung von Gesellschaftsrechten, zum Teil aber auch in anderen Entgelten (Zahlung eines Barkaufpreises, Einräumung einer Forderung, Übernahme von Schulden des Gesellschafters) besteht.

Die Übertragung im Wege der verdeckten Einlage, für die der Steuerpflichtige also keine Gegenleistung erhält, führt mangels Veräußerung zu keinem Objekt.

3.2.5 Die „Zählobjekte“

Die maßgebenden Objekte, bei denen ein enger zeitlicher Zusammenhang (i. d. R. fünf Jahre) zwischen Errichtung, Erwerb oder Modernisierung und der Veräußerung besteht, stellen jeweils „Zählobjekte“ dar.

3.2.6 Die Drei-Objekt-Grenze

3.2.6.1 Merkmale der Drei-Objekt-Grenze



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Drei-Objekte-Grenze – v10618

Für die Beurteilung der Frage, ob im Hinblick auf die Veräußerung von Grundstücken ein gewerblicher Grundstückshandel gegeben ist, hat die Rechtsprechung zur Vereinfachung die sog. Drei-Objekt-Grenze entwickelt:

Die Veräußerung von **mehr als drei Zählobjekten** innerhalb eines Fünfjahreszeitraums ist grundsätzlich gewerblich, BMF 1 § 15/1, Rz. 5.

Zum gewerblichen Grundstückshandel gehören in diesen Fällen auch die Veräußerungen der ersten drei Objekte (neue Tatsache i. S. d. § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO; BMF 1 § 15/1, Rz. 33).



HINWEIS

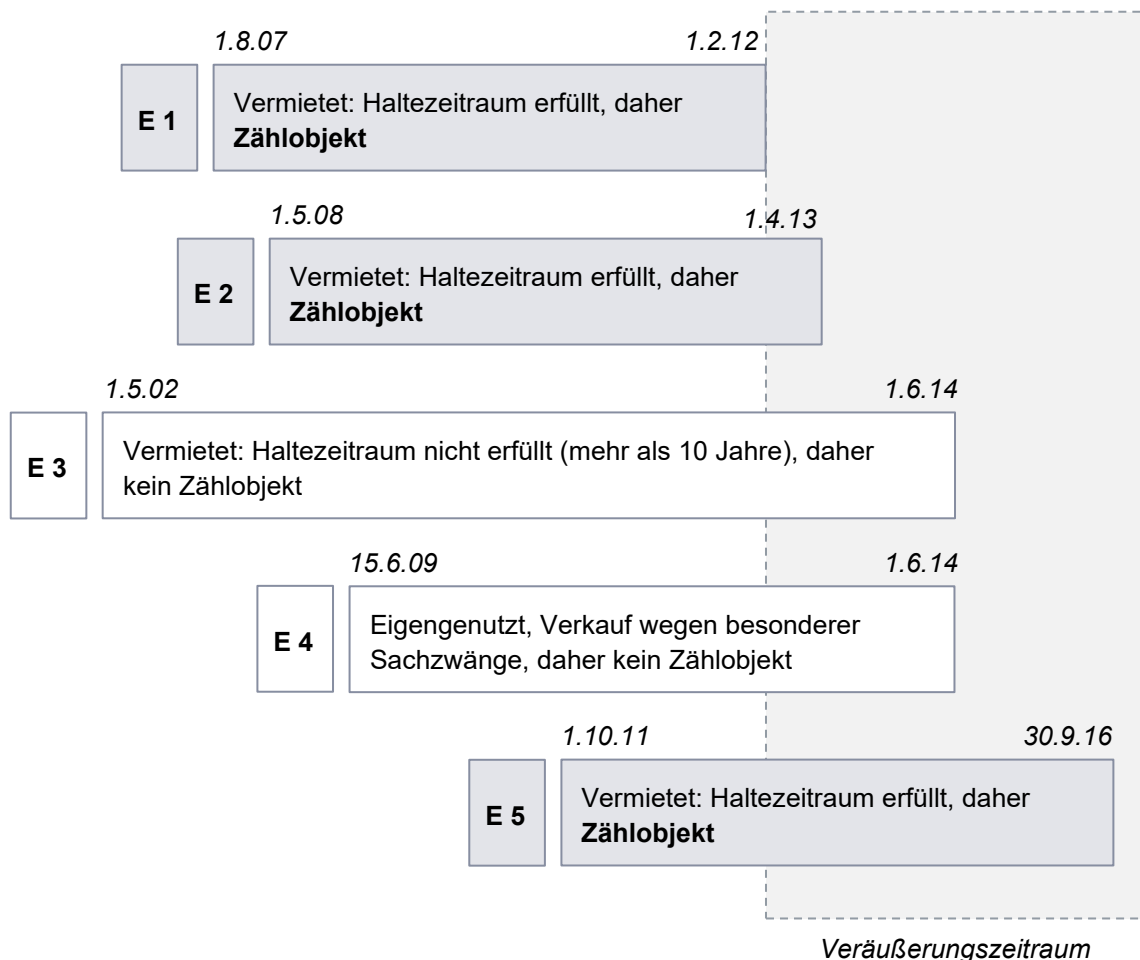
Mit Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze ist regelmäßig der Tatbestand „Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr“ erfüllt. Für das Vorliegen von Einkünften aus Gewerbebetrieb aus einem gewerblichen Grundstückshandel muss aber zusätzlich auch das Tatbestandsmerkmal der „Nachhaltigkeit“ erfüllt sein.

Nachhaltigkeit setzt zumindest eine Wiederholungsabsicht voraus. Nach Auffassung des BFH indiziert das Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze nicht die Nachhaltigkeit. Diese liegt nur dann vor, falls noch andere derartige Grundstücksgeschäfte geplant waren.

Ansonsten liegt nur ein einheitlicher Verkaufsentschluss vor, der mit nur einer Handlung umgesetzt wurde. Folglich ist mangels Wiederholungsabsicht keine Nachhaltigkeit und damit kein gewerblicher Grundstückshandel gegeben.

► Beispiel:

Der Stpfl. A besitzt mehrere Einfamilienhäuser (E1-E5), die er zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben und veräußert hat. Die Entwicklung stellt sich im Überblick wie folgt dar:



► Lösung:

Die Grundstücke E1, E2 und E5 stellen Objekte i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels dar (BMF 1 § 15/1, Rz. 8). Da auch die fünfjährige Haltefrist erfüllt ist, liegen Zählobjekte vor. Das Grundstück E3 gehört wegen der mehr als 10-jährigen Vermietung zur privaten Vermögensverwaltung (BMF 1 § 15/1, Rz. 2 Satz 1), das Grundstück E4 ist als eigengenutzte Wohnung,

deren Veräußerung auf offensichtlichen Sachzwängen beruht, trotz des engen zeitlichen Zusammenhangs (Haltezeitraum) nicht zu berücksichtigen (BMF 1 § 15/1, Rz. 10).

Da innerhalb des maßgebenden Veräußerungszeitraums (Beginn mit Veräußerung des ersten Zählobjekts am 1.2.12) nicht mehr als drei Zählobjekte veräußert werden, liegt derzeit kein gewerblicher Grundstückshandel vor (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).

Würde in der Zeit bis zum Ablauf des 1.2.17 noch ein weiteres Zählobjekt veräußert werden, wäre rückwirkend ab 1.2.12 ein gewerblicher Grundstückshandel gegeben (BMF 1 § 15/1, Rz. 33).

► **Beispiel:**

S hat von seinem in 15 verstorbenen Vater V drei bebaute Grundstücke geerbt, die V 15 Jahre vorher im Privatvermögen erworben hatte. Zwei dieser Grundstücke werden von S Ende 16 veräußert, wobei er das Gebäude eines dieser beiden Grundstücke vor der Veräußerung grundlegend modernisiert hat. S selbst hatte in den Jahren 13 und 14 drei eigene Grundstücke veräußert, die er jeweils drei Jahre vorher erworben hatte.

► **Lösung:**

Die drei verkauften eigenen Grundstücke des S sind Objekte (BMF 1 § 15/1, Rz. 8), die, da innerhalb der Haltefrist angeschafft und veräußert, auch Zählobjekte darstellen. Die im Erbwege erworbenen Grundstücke sind grds. keine Objekte; allerdings setzt S durch die grundlegende Modernisierung eines der Grundstücke insoweit selbst eine Ursache, die durch die zeitnahe Veräußerung auf eine bedingte Veräußerungsabsicht schließen lässt – damit ist das modernisierte Grundstück ebenfalls ein Zählobjekt (BMF 1 § 15/1, Rz. 9).

Da innerhalb des maßgebenden Veräußerungszeitraums (Beginn mit Veräußerung des ersten Zählobjekts in 13) mehr als drei Zählobjekte veräußert werden, liegt ein gewerblicher Grundstückshandel vor (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).

3.2.6.2 Durch vorweggenommene Erbfolge/Schenkung erworbene Grundstücke



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unentgeltliche Übertragungen – v10619

Unentgeltlich durch Einzelrechtsnachfolge erworbene Grundstücke stellen grds. keine Objekte dar. Etwas anderes gilt nach BMF 1 § 15/1, Rz. 9 falls das Grundstück in zeitlichem Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung veräußert wird.

In diesen Fällen sind bei der Beurteilung der Drei-Objekt-Grenze Rechtsvorgänger und Rechtsnachfolger als „eine Einheit“ anzusehen („steuersubjektübergreifende“ Drei-Objekt-Grenze).

Das heißt, dass Veräußerungen durch den Rechtsnachfolger, die in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung oder ggf. Bebauung durch den Rechtsvorgänger stehen, **und** derartige Veräußerungen durch den Rechtsvorgänger bei der Prüfung der Drei-Objekt-Grenze zusammenzurechnen sind. Dies führt zu gewerblichen Einkünften

- beim Rechtsvorgänger hinsichtlich der veräußerten Grundstücke.
- beim Rechtsnachfolger hinsichtlich der unentgeltlich erworbenen und veräußerten Grundstücke.

(BMF 1 § 15/1, Rz. 9 mit Beispiel)

► **Beispiel:**

Der Vater V hatte in den Jahren 13 bis 15 drei Zählobjekte veräußert. In 16 überträgt er ein bisher vermietetes Zweifamilienhaus, das er im Jahre 12 erworben hatte, im Wege der Schenkung auf seine Tochter T, die selbst noch keine Grundstücksgeschäfte getätigt hatte. T veräußert das Grundstück noch in 16.



► **Lösung:**

Das im Wege der Einzelrechtsnachfolge auf T übertragene Grundstück stellt zunächst kein Zählobjekt dar. Bei T würde sich grds. ein privates Veräußerungsgeschäft ergeben, da ihr die Besitzzeit des V gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG zuzurechnen wäre.

Nach BMF 1 § 15/1, Rz. 9 ist hier allerdings die Drei-Objekt-Grenze steuersubjektübergreifend zu prüfen. Die Veräußerung des Zweifamilienhauses durch T innerhalb des Haltezeitraums (12 – 16) führt bei V zur Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels hinsichtlich seiner drei Objekte.

Daneben erzielt auch T Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Zusammenrechnung der Veräußerungen von V und T = mehr als drei Objekte). Bei T wäre das unentgeltlich erworbene Grundstück für die Frage eines eigenen gewerblichen Grundstückshandels als Zählobjekt zu berücksichtigen.

3.2.6.3 Veräußerung des Anteils an einer Grundstücksgesellschaft

(BMF 1 § 15/1, Rz. 18)

Bei der Veräußerung von Anteilen an Grundstücksgesellschaften ist in der Person des die Beteiligung veräußernden Gesellschafters ein gewerblicher Grundstückshandel zu prüfen.

► **Beispiel:**

A veräußerte im Jahre 14 seine 30%ige Beteiligung an der ABC-GbR (Erwerb 10) sowie im Jahre 16 seinen 50%igen Anteil an der ADF-GbR (Erwerb 13). Zum Gesellschaftsvermögen beider GbRs gehören jeweils zwei Grundstücke, die sowohl bei Eintritt als auch bei Ausscheiden des A vorhanden waren.

► **Lösung:**

Die Veräußerung des Anteils an der ADF-GbR löst für A einen gewerblichen Grundstückshandel aus, da zur Beurteilung der Drei-Objekt-Grenze in der Person des A die zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Grundstücke jeweils als eigenständige Objekte zu beurteilen sind. Demnach liegen bei A in 16 insgesamt vier Zählobjekte vor (Haltezeitraum bzgl. ABC-GbR: Erwerb Anteil 10 – Verkauf Anteil 14, Haltezeitraum bzgl. ADF-GbR: Erwerb Anteil 13 – Verkauf Anteil 16). A hat im maßgeblichen Veräußerungszeitraum (Beginn mit Veräußerung des Anteils an der ABC-GbR) mehr als drei Zählobjekte veräußert. Die Veräußerungen der Anteile erfolgen daher jeweils im Rahmen von Einkünften aus Gewerbebetrieb.

Darüber hinaus sind in Bezug auf den Haltezeitraum folgende weitere Konstellationen zu beachten:

- Ein bei Eintritt des Gesellschafters vorhandenes Grundstück wird von der Gesellschaft bis zu dessen Ausscheiden veräußert: Maßgebender Haltezeitraum ist der Zeitraum zwischen Eintritt des Gesellschafters und der Veräußerung des Grundstücks (Schmidt/Wacker EStG, § 15 Rz. 74).
- Die Gesellschaft erwirbt nach Eintritt, aber vor Ausscheiden des Gesellschafters ein Grundstück: Maßgebender Haltezeitraum ist der Zeitraum zwischen Erwerb des Grundstücks durch die Gesellschaft und dem Ausscheiden des Gesellschafters.
- Während der Gesellschafterphase kauft und verkauft die Gesellschaft ein Grundstück: Maßgebender Haltezeitraum ist der Zeitraum zwischen Erwerb und Veräußerung des Grundstücks durch die Gesellschaft.

► **Beispiel:**

B veräußerte im Jahre 16 seine 50%ige Beteiligung an der BC-GbR, die er im Jahre 02 erworben hatte. Im Gesellschaftsvermögen befinden sich bei Anteilsveräußerung zehn Grundstücke, von denen fünf in den Jahren 12 bis 16 angeschafft worden waren.

► **Lösung:**

Sämtliche bei Ausscheiden des B in 16 vorhandenen Grundstücke der GbR stellen Objekte für B dar. Nur die innerhalb der letzten fünf Jahre vor Ausscheiden des B angeschafften Objekte sind als Zählobjekte (Haltezeitraum) zu beurteilen. Damit ist bei B die Drei-Objekt-Grenze überschritten – die Veräußerung seines Anteils führt insoweit zu Einkünften aus Gewerbebetrieb.

3.2.6.4 Veräußerungen durch Ehegatten/Lebenspartner

Jeder Ehegatte/Lebenspartner hat eine eigene Drei-Objekt-Grenze.

Bei Veräußerung eines im Miteigentum der Ehegatten/Lebenspartner stehenden Grundstücks stellt der jeweilige Anteil am Grundstück für jeden der Ehegatten/Lebenspartner ein eigenständiges Objekt dar.

Eine Zusammenrechnung von Grundstücksgeschäften der Ehegatten liegt ausnahmsweise nur dann vor, wenn eine über die eheliche Lebensgemeinschaft hinausgehende zusätzliche enge Wirtschaftsgemeinschaft (z. B. in Form einer GbR) eingegangen wird (BMF 1 § 15/1, Rz. 12).

► **Beispiel:**

Die Ehegatten A und B veräußern im Jahre 16 ein vermietetes Einfamilienhaus, das sie im Jahre 13 zu je ½ erworben hatten. A hat seit 12 bereits drei und B zwei Zählobjekte veräußert.

► **Lösung:**

Die Veräußerung des Einfamilienhauses im Jahre 16 führt bei A zu einem gewerblichen Grundstückshandel: Verkauf von drei eigenen Objekten und Verkauf des Objekts „Miteigentumsanteil“ (= vier Objekte).

B überschreitet mit dem Objekt „Miteigentumsanteil“ die Drei-Objekt-Grenze nicht. B hat insoweit weitere sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern.

3.2.6.5 Gewerblicher Grundstückshandel ohne Überschreitung der Drei-Objekt-Grenze



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unbedingte Veräußerungsabsicht – v10620

Die „Drei-Objekt-Grenze“ ist grundsätzlich auch auf Fälle anzuwenden, in denen der Grundstücksveräußerer ein Wohnobjekt selbst **gebaut** hat (BMF 1 § 15/1, Rz. 19, 20).

Allerdings muss die als Indiz wirkende „Drei-Objekt-Grenze“ durch besondere Fakten überlagert werden. So können besondere Umstände auch bei Veräußerungen von weniger als vier Objekten in zeitlicher Nähe zu ihrer Errichtung für die Gewerblichkeit sprechen (es handelt sich nicht um eine absolut wirkende „Freigrenze“). Wann dies der Fall sein kann, hängt von den besonderen Umständen der Veräußerung oder der Art der veräußerten Objekte ab. Entscheidend ist, dass aufgrund objektiver Umstände feststeht, dass die Aktivitäten zur Erhöhung des Grundstückswertes (Bebauung, Erschließungsmaßnahmen) in **unbedingter Veräußerungsabsicht** ausgeübt wurden (BFH, Urteil v. 4.7.2006 – IV B 59/05, BFH/NV 2006, S. 2063).

Bei **errichteten Wohnobjekten** (Einfamilien-, Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen) kommt ein gewerblicher Grundstückshandel auch bei Veräußerung von weniger als vier Grundstücken insbesondere dann in Betracht, wenn

- das Grundstück bereits vor der Bebauung, also bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten, durch den Veräußerer verkauft wird,
- das Grundstück von vornherein auf Rechnung und nach Wünschen des Erwerbers bebaut wird,
- das Bauunternehmen des Steuerpflichtigen erhebliche Leistungen für den Bau erbringt, die nicht wie unter fremden Dritten abgerechnet werden,



- das Bauvorhaben nur kurzfristig finanziert wird,
- der Steuerpflichtige bereits während der Bauzeit einen Makler für den Verkauf des Objekts beauftragt,
- vor Fertigstellung ein Vorvertrag mit dem künftigen Erwerber abgeschlossen wird,
- der Steuerpflichtige über den bei Privatverkäufen üblichen Rahmen hinaus Gewährleistungspflichten übernimmt oder
- unmittelbar nach dem Erwerb des Grundstücks mit der Bebauung begonnen und das Grundstück unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten veräußert wird.

(BMF 1 § 15/1, Rz. 28)



HINWEIS

Der BFH hat im Urteil v. 28.4.2005 – IV R 17/04, BStBl II 2005, S. 606 vorstehende Rechtsprechung bestätigt. Er weist jedoch darauf hin, dass für den Fall, dass zwischen der Beauftragung der Bauhandwerker und dem Baubeginn ein Ereignis eintritt, das die ursprünglich vorhandene Vermietungsabsicht vereitelt (Versagung der in Aussicht gestellten Baugenehmigung) und einen Verkauf notwendig macht, es dafürspricht, dass die Bebauung trotz der Veräußerung durch die ursprüngliche Vermietungsabsicht veranlasst ist.

Der lediglich zeitliche Zusammenhang zwischen Erwerb/Bebauung und Veräußerung führt für sich allein zu keiner unbedingten Veräußerungsabsicht.

Bei Veräußerungen von errichteten Großobjekten, wie z. B. **Mehrfamilienhäusern, Büro-, Hotel-, Fabrik- oder Lagergrundstücken**, kann ein gewerblicher Grundstückshandel auch bei der Veräußerung von weniger als vier Objekten vorliegen. Dies ist aber auch hier nur dann der Fall, wenn der Steuerpflichtige über die reine Veräußerung hinaus weitere Leistungen erbringt, die eine Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nach sich ziehen können.

In diesem Zusammenhang verweist das BMF 1 § 15/1, Rz. 29 auf BFH v. 24.1.1996, BStBl 1996 II, S. 303 (Errichtung von zwei Supermärkten, die jeweils nach kurzer Pachtdauer an den Pächter veräußert wurden) und BFH v. 14.1.1998, BStBl 1998 II, S. 346 (Errichtung und Veräußerung eines Sechsfamilienhauses). In diesen Fällen kam der BFH zu einem gewerblichen Grundstückshandel, weil der Erwerb eines Grundstücks, dessen anschließende Bebauung (mit einem Großobjekt) und zeitnahe Veräußerung „als gewerbliche Wertschöpfung nach Art eines Bauunternehmers/Bauträgers zu beurteilen sei, weshalb es auf die „Drei-Objekt-Grenze“ nicht ankomme“.

Auch in diesem Zusammenhang ist das Tatbestandsmerkmal der „**Nachhaltigkeit**“ zu prüfen. Nach Auffassung des BFH kann Nachhaltigkeit auch dann vorliegen, wenn der Stpfl. in Fällen der Errichtung zwar nur ein einziges (Veräußerungs-)Geschäft abschließt und sich darüber hinaus keine Wiederholungsabsicht feststellen lässt, er aber zur Erfüllung dieses einzigen Geschäfts eine Vielzahl von unterschiedlichen Einzeltätigkeiten ausführt, die in ihrer Gesamtheit als nachhaltige Betätigung zu würdigen sind.

So hat beispielsweise der BFH eine nachhaltige Betätigung angenommen, falls der Stpfl. (kumulativ)

- in unbedingter Veräußerungsabsicht eine Bauplanung für das Grundstück hat erstellen lassen,
- im Interesse potenzieller Erwerber Mietverträge abgeschlossen hat,
- bei Gesamtbaukosten von 6 Mio. € und einem Gewinn von fast 2 Mio. € mehrere Bauunternehmer beauftragt hat,
- sich zur Gewährleistung für Baumängel und
- zur Zahlung von Schadensersatz für Mietausfälle bei nicht rechtzeitiger Fertigstellung verpflichtet hat.

Mit BFH, Urteil v. 19.2.2009, BStBl II 2009, S. 533 knüpfte der Senat an die oben dargestellten Kriterien der Nachhaltigkeit an. Demnach sind für Zwecke der Nachhaltigkeit die Leistungen eines Generalunternehmers dem Bauherrn jeweils gesondert als Einzelaktivitäten zuzurechnen, falls diese insgesamt über das hinausgehen, was zum Bau eines Hauses gewöhnlich erforderlich ist.

3.2.6.6 Kein gewerblicher Grundstückshandel bei Überschreitung der „Drei-Objekt-Grenze“

Das Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze führt ausnahmsweise zu keinem gewerblichen Grundstückshandel, wenn auf Grund besonderer, vom Stpfl. darzulegender Umstände eindeutige Anhaltspunkte gegen eine von Anfang an bestehende bedingte Veräußerungsabsicht sprechen.

Die Finanzverwaltung erkennt derartige Umstände in der vom Veräußerer selbst vorgenommenen langfristigen – über fünf Jahre hinausgehenden – Vermietung eines Wohnobjekts an. Indiz für eine auf Dauer angelegte Wohnnutzung können auch vom Stpfl. durchgeführte Baumaßnahmen sein, die individuell auf dessen besondere Wohnbedürfnisse ausgerichtet sind.

Plötzliche Erkrankung, Finanzierungsschwierigkeiten, schlechte Vermietbarkeit, Scheidung, nachträgliche Entdeckung von Baumängeln und unvorhergesehene Notlagen sind im Regelfall nicht geeignet, die aufgrund des zeitlichen Abstands der maßgebenden Tätigkeiten vermutete (bedingte) Veräußerungsabsicht im Zeitpunkt der Anschaffung oder Errichtung auszuschließen (BMF 1 § 15/1, Rz. 30).

3.2.7 Beginn, Umfang und Beendigung des gewerblichen Grundstückshandels, Gewinnermittlung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gewinnermittlung – v10621

3.2.7.1 Beginn des Grundstückshandels

Ein gewerblicher Grundstückshandel entsteht regelmäßig zu dem Zeitpunkt, in dem der Steuerpflichtige mit Tätigkeiten beginnt, die objektiv erkennbar auf die Vorbereitung der Grundstücksgeschäfte gerichtet sind.

Dabei ist wie folgt zu unterscheiden:

- Beim **Erwerb** und der Veräußerung in einem engen zeitlichen Zusammenhang beginnt der gewerbliche Grundstückshandel im Allgemeinen im Zeitpunkt des Grundstückserwerbs, und zwar mit dem Erwerb des ersten in den Grundstückshandel einzubeziehenden Grundstücks.
- Bei der **Errichtung** und der Veräußerung in einem engen zeitlichen Zusammenhang beginnt der gewerbliche Grundstückshandel grundsätzlich mit der Stellung des Bauantrags, bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben mit der Einreichung der Bauunterlagen oder dem Beginn der Herstellung (R 7.2 Abs. 4 EStR). Beginn der Herstellung ist u. a. dann gegeben, wenn auf dem Bauplatz erhebliche Mengen an Baumaterial und Bauteile angeliefert worden sind.
- Bei **grundlegender Modernisierung bzw. Sanierung** von Objekten und Veräußerung in einem engen zeitlichen Zusammenhang beginnt der gewerbliche Grundstückshandel in dem Zeitpunkt, in dem mit den Modernisierungs- bzw. Sanierungsarbeiten begonnen wird.
- In den Fällen eines **Erwerbs eines ungeteilten Objekts** und erst späterer Teilung kann die gewerbliche Tätigkeit bereits mit dem Erwerb des Grundstücks beginnen. Die gewerbliche Tätigkeit beginnt daher nicht zwingend frühestens mit der Teilung des Grundstücks. In den Fällen des Erwerbs bzw. der Errichtung/Modernisierung eines (noch ungeteilten) Mehrfamili-



enhausen bzw. Mietwohngrundstücks führen zwar regelmäßig erst die Teilung und der anschließende Verkauf einzelner Wohnungen dazu, dass sich die Tätigkeit des Steuerpflichtigen nicht mehr als bloße private Vermögensverwaltung, sondern als gewerblicher Grundstückshandel erweist. Dies bedeutet aber nicht, dass diese gewerbliche Tätigkeit erst mit der Teilung beginnt (BMF 1 § 15/1, Rz. 31).

3.2.7.2 Umfang des Grundstückshandels

Der Umfang eines gewerblichen Grundstückshandels ergibt sich in der Regel aus dem veräußerten Grundbesitz. Dabei muss auch die Vermutung des § 344 Abs. 1 HGB beachtet werden, wonach die von einem Kaufmann vorgenommenen Rechtsgeschäfte im Zweifel als zum Betrieb des Handelsgewerbes gehörend anzusehen sind. Diese Zugehörigkeitsvermutung greift insbesondere bei branchengleichen Wirtschaftsgütern.

Darüber hinaus erfolgt die Prüfung des Umfangs der gewerblichen Tätigkeit bei einem bereits bestehenden gewerblichen Grundstückshandel nach den gleichen Kriterien wie die Abgrenzung des gewerblichen Grundstückshandels von der privaten Vermögensverwaltung. Demzufolge können zum gewerblichen Grundstückshandel stets nur (tatsächliche) Zählobjekte i. S. eines gewerblichen Grundstückshandels gehören (BMF 1 § 15/1, Rz. 32).

3.2.7.3 Gewinnermittlung

Die Gewinnermittlung erfolgt durch Betriebsvermögensvergleich (§ 5 Abs. 1 EStG; Regelgewinnermittlungsart).

Eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist möglich, wenn der Steuerpflichtige nicht gemäß § 140 AO i. V. m. § 238 ff. HGB Bücher führt oder die Grenzen des § 141 AO nicht überschreitet. Das Wahlrecht zu § 4 Abs. 3 EStG entfällt erst mit der Erstellung eines Abschlusses (H 4.5 Abs. 1 EStH „Wahl der Gewinnermittlungsart“). Es setzt voraus, dass sich der Steuerpflichtige von Beginn an bewusst ist, Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu erzielen.

Die Grundstücke stellen Umlaufvermögen dar. AfA, erhöhte Abschreibungen und Sonderabschreibungen sind deshalb nicht möglich. Eventuelle Mieterträge führen zu Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 21 Abs. 1 und 3 EStG; BMF 1 § 15/1, Rz. 32).

Bei der erstmaligen Begründung eines gewerblichen Grundstückshandels durch Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze treten die Rechtsfolgen eines gewerblichen Grundstückshandels rückwirkend ein. Daher sind auch die Veräußerungen der ersten drei Zählobjekte gewerblich (für bestandskräftige Steuerfestsetzungen Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). In diesen Fällen bestehen keine Bedenken, den nachträglich zu ermittelnden Gewinn ausgehend vom Veräußerungserlös abzüglich der fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. des Einlagewertes sowie der Veräußerungskosten zu berechnen (BMF 1 § 15/1, Rz. 33).

► **Beispiel:**

A hatte in 06 aus Mitteln einer umfangreichen Erbschaft insgesamt fünf im Teileigentum stehende Räumlichkeiten angeschafft, die seitdem als Büroräumlichkeiten vermietet sind. Drei dieser Objekte veräußert A in 10 an die jeweiligen bisherigen Mieter. Anfang 11 veräußert A ein weiteres dieser Objekte.

► **Lösung:**

Bei der erstmaligen Begründung eines gewerblichen Grundstückshandels durch Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze (hier Anfang 11) treten die Rechtsfolgen eines gewerblichen Grundstückshandels rückwirkend ein. Daher sind auch die Veräußerungen der ersten drei Zählobjekte gewerblich; für bestandskräftige Steuerfestsetzungen erfolgt eine Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO (BMF 1 § 15/1, Rz. 33).

Die Grundstücke stellen Umlaufvermögen dar. AfA, erhöhte Abschreibungen und Sonderabschreibungen sind deshalb nicht möglich. Eventuelle Mieterträge führen zu Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 21 Abs. 1 und 3 EStG; BMF 1 § 15/1 Rz. 32).

3.2.7.4 Wertansatz

Mit Entstehen des gewerblichen Grundstückshandels sind die Zählobjekte, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Eigentum des Steuerpflichtigen standen und bisher Privatvermögen darstellten, mit dem Wert nach **§ 6 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. Nr. 5 EStG** zu erfassen. Spätere Zählobjekte sind mit ihren Anschaffungskosten zu berücksichtigen (BMF 1 § 15/1, Rz. 34).

► **Beispiel:**

Der Stpfl. X veräußerte im April 14 zwei bebaute Grundstücke, die er jeweils im Januar 12 erworben hatte. Im Juni 14 veräußerte X ein Grundstück, das er vor 17 Jahren als unbebautes Grundstück erworben und im Jahr 13 mit einem Einfamilienhaus bebaut hatte. Im November 15 veräußert X ein weiteres Grundstück, das er 06 ebenfalls als unbebautes Grundstück erworben und 14 mit einem Zweifamilienhaus bebaut hatte.

► **Lösung:**

Sämtliche verkauften Grundstücke stellen Objekte i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels dar (BMF 1 § 15/1, Rz. 8). Die fünfjährigen Haltezeiträume – Kauf und Verkauf bzw. Bebauung und Verkauf – sind jeweils erfüllt, daher liegen Zählobjekte vor.

Da innerhalb des maßgebenden Veräußerungszeitraums (Beginn mit Veräußerung der ersten Zählobjekte im April 14) mehr als drei Zählobjekte veräußert werden, liegt ein gewerblicher Grundstückshandel vor (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).

Die im Jahr 12 erworbenen Grundstücke sind mit den AK zu berücksichtigen (Beginn des gewerblichen Grundstückshandels), die übrigen beiden Grundstücke sind mit ihren Teilwerten (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 HS 1 EStG) bei Baubeginn in den Betrieb „gewerblicher Grundstückshandel“ einzulegen.

3.2.7.5 Beendigung des Grundstückshandels

Der gewerbliche Grundstückshandel endet mit der Veräußerung des letzten Objekts oder der Aufgabe des Betriebs (endgültige Einstellung der Verkaufstätigkeit). Auch wenn der Betrieb aufgegeben wird, handelt es sich bei dem Aufgabegewinn **um einen laufenden Gewinn**, der nicht tarifermäßig besteuert werden kann (BMF 1 § 15/1, Rz. 35).



HINWEIS

Das Fehlen jeglicher Verkaufsbemühungen oder anderer nachweisbarer Vermarktungshandlungen nach dem Scheitern weiterer Umbauarbeiten und die Vermietung der fertig gestellten Wohneinheiten kann allenfalls als Einstellung der werbenden Tätigkeit, nicht jedoch als abgeschlossene Betriebsaufgabe eines gewerblichen Grundstückshandels gewertet werden.

Das Unterlassen geeigneter Umstrukturierungsmaßnahmen ist jedoch als gewichtiges Anzeichen für eine fehlende Gewinnerzielungsabsicht zu werten.



II. LIEBHABEREI IM EINKOMMENSTEUERRECHT

1. Begriff



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Liebhaberei – v10622

Der Begriff der Liebhaberei wird weder im EStG verwendet, noch ist er in anderen gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich definiert. Er wurde von der Rechtsprechung durch die Auslegung des in § 2 Abs. 1 Satz 1 EStG genannten Begriffs des Steuergegenstandes gewonnen.

Wird eine Tätigkeit nicht des Erwerbs wegen, sondern zur Befriedigung persönlicher Neigungen (z. B. Freizeitgestaltung, Erholung) ausgeübt, handelt es sich um eine sog. „Liebhabereitätigkeit“.

Daneben ist es auch möglich, dass eine zunächst vorhandene Einkünfterzielungsabsicht später wegfällt, z. B., wenn trotz langjähriger Verluste die Tätigkeit unverändert fortgeführt wird.

2. Einkünfterzielungsabsicht

Einkünfterzielung setzt bei allen Einkunftsarten das Streben nach einem Gewinn i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG bzw. nach einem Einnahmenüberschuss i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG voraus, da der Steuergegenstand in § 2 Abs. 1 EStG dahingehend beschrieben ist, dass der Einkommensteuer diejenigen Einkünfte unterliegen, die der Steuerpflichtige erzielt hat.

Bei betrieblichen Einkünften ist somit Voraussetzung, dass die Verluste durch Gewinne mehr als ausgeglichen werden können (sog. **Totalgewinnprognose** = Zeitraum zwischen Gründung und Liquidation des Unternehmens, H 15.3 EStH „Totalgewinn“).

Da auf die nach den steuerlichen Vorschriften ermittelten Gewinne bzw. Einnahmenüberschüsse abzustellen ist, ist eine sich bei der Berücksichtigung von Verlusten ergebende Steuerminderung außer Betracht zu lassen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 EStG).

3. Persönlicher Geltungsbereich

Der Begriff der Liebhaberei gilt für alle unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen. Er ist auch bei den Steuersubjekten i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 – 6 KStG anwendbar.

Einkünfte aus Liebhabereitätigkeiten sind steuerlich unbeachtlich, d. h. Verluste dürfen nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen werden, evtl. Zufallsgewinne sind nicht steuerpflichtig, bleiben also außer Betracht.

Sie sind nicht der Erwerbssphäre (Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 – 7 EStG), sondern der Privatsphäre, d. h. dem Bereich der Einkünfteverwendung zuzuordnen.

► Beispiel:

C ist Inhaber eines Führerscheins für Motorboote. Im Jahr 02 nutzte er die Gelegenheit, eine Motoryacht günstig zu erwerben. Um die Yacht wenigstens zeitweise in Betrieb zu halten, veröffentlicht er einmal im Jahr eine kleine Anzeige in einem Lokalblatt, mit der er die Yacht zur Vermietung anbietet. Der tägliche Mietpreis deckt die tatsächlichen Kosten, die für den Unterhalt und die Wartung anfallen, nur zu ca. 70 %. In seine Kalkulation einbezogen hat C die Steuerersparnis, durch die sowohl das Defizit bei den Unterhalts- und Wartungskosten als auch die Finanzierungskosten und die laufende Abschreibung abgedeckt wird.

► **Lösung:**

Die Vermietung des Bootes ist nicht geeignet, einen Totalgewinn zu erzielen, da sich bereits aus der Höhe des täglichen Charterpreises ergibt, dass ein positives Ergebnis nicht angestrebt wird. Es ist auch objektiv unmöglich ein solches zu erreichen, da in die Kalkulation weder die Finanzierungskosten für die Anschaffung noch die laufende Abschreibung Eingang gefunden haben.

Die Absicht, durch die Vermietung Steuern zu sparen, gilt nicht als Gewinnerzielungsabsicht (§ 15 Abs. 2 Satz 2 EStG).



III. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 35 Minuten

Der Stpfl. A tritt in die bestehende BCD-OHG als weiterer Gesellschafter ein. Die Gesellschaftereinlage für den 25%igen Gesellschaftsanteil wird am 1.7.16 durch Einbringung eines unbebauten Grundstücks geleistet; der Verkehrswert des Grundstücks beträgt 300.000 €.

A hatte das unbebaute Grundstück Ende 12 im Privatvermögen erworben (Anschaffungskosten 260.000 €).

A hatte Ende 13, Ende 14 und Ende 15 (notarieller Vertrag u. Übergang Nutzen u. Lasten) jeweils ein vermietetes Einfamilienhaus veräußert; Veräußerungspreis jeweils 500.000 €. Diese Grundstücke hatte A jeweils eineinhalb Jahre vor der Veräußerung erworben (Anschaffungskosten jeweils 460.000 €). Bis zur jeweiligen Veräußerung hatte A für jedes vermietete Einfamilienhaus eine (zutreffende) Jahres-AfA i. H. v. 6.000 € als Werbungskosten i. R. d. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abgezogen. Da A sich über die Jahre ein Fachwissen und Marktkenntnisse angeeignet hat, möchte er diese nach dem Eintritt in die BCD-OHG weiterhin für individuelle Immobilienkäufe und -verkäufe nutzen.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Einkünfte des A in 16. Sofern sich daraus auch einkommensteuerliche Auswirkungen auf andere Veranlagungszeiträume ergeben, sind diese ohne Berechnungen darzustellen

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 10 Minuten

Der Stpfl. B hat im Jahr 14 aus seinem Privatvermögen ein unbebautes Grundstück veräußert, das er in 11 erworben hatte. B ist zudem seit 09 an der ABC-GbR zu 33 ⅓ % beteiligt. Die GbR hat in den Jahren 14, 15 und 16 jeweils ein unbebautes Grundstück veräußert; die Grundstücke wurden jeweils zwei Jahre vor der Veräußerung erworben.

AUFGABE

Welche Auswirkungen ergeben sich? Begründen Sie Ihre Antwort.

3. Übungsfall 3

Bearbeitungszeit ca. 5 Minuten

Der Stpfl. C ist zu je ⅓ an den vermögensverwaltenden Grundstücksgesellschaften CDE-GbR bzw. CFG-GbR beteiligt; beide Gesellschaftsanteile stellen bei C Privatvermögen dar. Sowohl die CDE-GbR als auch die CFG-GbR veräußerten in den Jahren 01 bis 03 jeweils zwei Grundstücke (Zählobjekte). Weitere Grundstücksgeschäfte tätigten weder die Gesellschaften noch C.

AUFGABE

Welche Auswirkungen ergeben sich? Begründen Sie Ihre Antwort.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 18 – v13929

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
1. Allgemeines		
Die Übertragung des unbebauten Grundstücks in 16 auf die OHG gegen Gewährung eines 25 %- Gesellschaftsanteils stellt eine Veräußerung des Grundstücks dar. Entscheidend ist damit, ob die Veräußerung i. R. einer privaten Vermögensverwaltung (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) oder eines Gewerbebetriebs (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) erfolgt.	1 1	
Die drei EFH-Grundstücke stellen sog. Zählobjekte dar, da zwischen Anschaffung und Veräußerung (Haltezeitraum) nicht mehr als fünf Jahre liegen und damit von einer bedingten Veräußerungsabsicht des A ausgegangen werden kann (BMF 1 § 15/1, Rz. 2, 8, 20, 22).	1 1	
Auch das unbebaute Grundstück stellt ein Zählobjekt dar, da der Haltezeitraum wiederum nicht mehr als 5 Jahre beträgt (BMF 1 § 15/1, Rz. 3, 20, 22).	1	
Da nunmehr innerhalb des maßgebenden fünfjährigen Veräußerungszeitraums (Beginn mit Veräußerung des ersten Zählobjektes im Jahr 13) mehr als drei Zählobjekte veräußert werden, liegt bei A ein gewerblicher Grundstückshandel vor (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).	1	
Der gewerbliche Grundstückshandel (= Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG) beginnt mit Erwerb des ersten Zählobjekts „EFH-Grundstück“ Mitte 12 (BMF 1 § 15/1, Rz. 31).	1	
Der gewerbliche Grundstückshandel endet mit Veräußerung des letzten Zählobjekts „unbebautes Grundstück“ am 1.7.16 (BMF 1 § 15/1, Rz. 35).	1	
Sämtliche Grundstücke des A stellen daher ab Anschaffung notwendiges BV dar (R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR, BMF 1 § 15/1, Rz. 32). In der steuerlichen Gewinnermittlung sind die Grundstücke jeweils mit den AK zu erfassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1, 3 EStG, BMF 1 § 15/1, Rz. 34).	1 1	
Die steuerliche Gewinnermittlung erfolgt durch BVV (§ 5 Abs. 1 EStG), da A kein Wahlrecht zu einer u. U. möglichen Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ausübte.	1	
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb 16		
Die Übertragung des unbebauten Grundstücks aus dem BV des A in das Gesamthandsvermögen der OHG stellt eine Veräußerung von Umlaufvermögen dar (vgl. Tz. 1; BMF 1 § 15/1, Rz. 33).	1	
Da die Übertragung des Grundstücks als einzelnes WG aus dem BV eines Mitunternehmers in das GHV der OHG gegen Gesellschaftsrechte erfolgt, hat dies nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG zwingend zum Buchwert zu erfolgen. Damit unterbleibt im Gewerbebetrieb des A in 16 jegliche Gewinnrealisierung.	2	



HINWEIS

Eine Einbringung nach § 24 Abs. UmwStG ist ausgeschlossen, weil A weiterhin am Immobilienmarkt tätig sein möchte. Er hat daher nicht einen Betrieb, sondern nur ein Einzel-WG in die OHG eingebracht.

3. Auswirkungen auf Veranlagungszeiträume vor 16		
Die Mieten aus den vermieteten EFH-Grundstücken sind in 12 bis 15 nicht im Rahmen von V+V-Einkünften, sondern i. R. von Einkünften aus Gewerbebetrieb zu erfassen (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 EStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).	1	
Nachdem die EFH-Grundstücke i. R. des gewerblichen Grundstückshandels Umlaufvermögen darstellen, sind AfA-Beträge unzulässig (BMF 1 § 15/1, Rz. 33).	1	
Aus den Veräußerungen der EFH-Grundstücke in 13, 14 und 15 erzielte A keine sonstigen Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nr. 2 EStG, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Die Gewinne aus der Veräußerung (Veräußerungserlös abzügl. BW) stellen betriebliche Erträge dar.	1	
Bisherige Steuerfestsetzungen für 12 bis 15 sind ggf. zu ändern (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Aus Vereinfachungsgründen könnten dabei die bisherigen AfA-Beträge unverändert bleiben und dafür die betrieblichen Erträge aus den Veräußerungen unter Berücksichtigung der fortgeführten AK ermittelt werden (BMF 1 § 15/1 Rz. 33).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	18	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 18 – v13930

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
1. Ebene der GbR		
Die verkauften unbebauten Grundstücke stellen Objekte i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels dar (BMF 1 § 15/1, Rz. 8). Die fünfjährige Haltefrist – Kauf und Verkauf – ist jeweils erfüllt, daher stellen die Grundstücke Zählobjekte dar.	1	
Auf der Ebene der Personengesellschaft liegt kein gewerblicher Grundstückshandel vor, denn insoweit ist die Drei-Objekt-Grenze nicht überschritten (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).	1	
2. Ebene des Gesellschafters B		
Das aus dem PV veräußerte Grundstück stellt ein Objekt i. S. d. gewerblichen Grundstückshandels dar (BMF 1 § 15/1, Rz. 8).	1	
Zusätzlich sind die Grundstücksgeschäfte der GbR bei dem Gesellschafter B wie eigene Aktivitäten (= Objekte) zu berücksichtigen, da er an der GbR zu mindestens 10 % beteiligt ist (BMF 1 § 15/1, Rz. 17). Die fünfjährigen Haltezeiträume – Kauf und Verkauf – sind jeweils erfüllt, daher liegen Zählobjekte vor.	1 1	
Da innerhalb des maßgebenden Veräußerungszeitraums (Beginn mit Veräußerung der ersten Zählobjekte in 14) mehr als drei Zählobjekte veräußert werden, liegt bei B ein gewerblicher Grundstückshandel vor (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).	1	
 HINWEIS <i>Die ABC-GbR ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, bei der die auf den Gesellschafter B entfallenden Veräußerungsgewinne wegen seines gewerblichen Grundstückshandels als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu qualifizieren sind. Demgegenüber erzielen die beiden übrigen Gesellschafter A und C aus den Grundstücksveräußerungen der GbR sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Die GbR stellt daher eine sog. „Zebra-Gesellschaft“ dar. Die Entscheidung über die Art und Höhe der Einkünfte eines betrieblich an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft beteiligten Gesellschafters hat das für die persönliche Besteuerung dieses Gesellschafters zuständige (Wohnsitz-)Finanzamt zu treffen.</i>		
Das unbebaute Grundstück des B ist mit den AK 11 (Beginn des gewerblichen Grundstückshandels) zu erfassen, der Verkauf im Jahr 14 führt zu einem betrieblichen Ertrag (ggf. „vereinfachte“ Gewinnermittlung entspr. BMF 1 § 15/1, Rz. 33 letzter Absatz).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	7	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 3 ESt 18 – v13931

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 3	Punkte	
	Soll	Ist
1. Ebene der GbR		
Auf der Ebene der Personengesellschaften liegt kein gewerblicher Grundstücks- handel vor, denn insoweit ist die Drei- Objekt-Grenze nicht überschritten (BMF 1 § 15/1, Rz. 5).	1	
2. Ebene des Gesellschafters C		
Die Grundstücksgeschäfte der beiden Grundstücksgesellschaften sind bei dem Gesellschafter C wie eigene Aktivitäten (= Objekte) zu berücksichtigen, da er an jeder GbR zu mindestens 10 % beteiligt ist (BMF 1 § 15/1, Rz. 17).	1	
Damit sind C insgesamt die Verkäufe von vier Zählobjekten zuzurechnen. C er- füllt daher in seiner Person die Voraussetzungen eines gewerblichen Grund- stückshandels (BMF 1 § 15/1, Rz. 17).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	3	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!